

1505480-24.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085858/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17036728 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 827/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2085858 - DEL.POL.SALTO, 827/21/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505480-24.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505480-24.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085858/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17036728 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 827/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2085858 - DEL.POL.SALTO, 827/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CÉSAR PEDROZO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra os réus CAIO CESAR PEDROZO e SERGIO DE SOUZA como incursos no art. 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, c.c. o art. 40, inciso III (entidade social e beneficente e recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza), da Lei Federal no 11.343/06, porque, em tese, no dia 28 de março de 2021, por volta das 20 horas, no cruzamento da Rua das Tulipas com a Rua Anselmo Duarte, nº 1, Vila Roma, nesta cidade e comarca de Salto/SP, os acusados, agindo em concurso, previamente ajustados e em unidade de desígnios, nas imediações da entidade social e beneficente "Casa de Belém" e de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 18 (dezoito) porções de "cocaína", com peso líquido de 5,9g (cinco gramas e nove decigramas),

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 29 de abril de 2021 (fls.142-148).

Os réus foram notificados pessoalmente e apresentaram defesa escrita (fls.154-170 e 202-208).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fl. 220-221) e os réus citados. Durante a instrução processual os réus foram interrogados e inquiridos duas testemunhas comuns.

A decisão de fls. 220-221, transitada em julgado, apreciou e rejeitou as preliminares de ausência de justa causa e ausência de acordo de não persecução penal.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a absolvição do réu CAIO CESAR PEDROZO por insuficiência probatória e condenação de SERGIO DE SOUZA nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição de ambos os réus por ausência de provas, alternativamente, a desclassificação em relação a Sérgio ou a fixação de pena no mínimo legal e substituição por pena restritiva de direitos. É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.08-10), auto de exibição e apreensão (fls.11), auto de constatação preliminar (fls.12) e laudo de exame químico toxicológico (fls.136-138) bem como por toda prova oral coligida nos autos. A autoria delitiva, por seu turno, restou demonstrada apenas em relação ao acusado Sérgio de Souza.

Os policiais militares Mario Bruno de Souza e Sylvio Tronchini Stein relataram, em resumo, que estavam em patrulhamento e viram um indivíduo abaixado num matagal, entre as ruas Anselmo Duarte e Rua Tulipa, local conhecido pela prática do tráfico de drogas. Tal indivíduo se levantou e foi até um veículo onix preto. O motorista do carro notou a aproximação da equipe e fugiu. Os dois indivíduos que estavam à pé foram abordados, com Sérgio, aquele que estava abaixado, foram localizadas 2 porções de cocaína. No local onde Sérgio estava abaixado, localizaram mais 16 porções de cocaína, idênticas àquelas que estavam na mão dele. Na posse de Caio, que estava parado ao lado do carro, foram localizados R\$ 45,00 (quarenta e cinco) reais.

O réu Sérgio de Souza, interrogado judicialmente, negou os fatos a ele imputados. Disse, em resumo, que tinha consigo duas porções de cocaína. É usuário. Foi até o matagal para urinar e usar a droga. A cocaína que foi achada pelos policiais no mato não era dele. Conhece Caio do trabalho.

O acusado Caio César Pedroso, interrogado, disse que trabalha na MK Logística e lá conheceu o réu Sérgio.. Na data dos fatos, saiu para comprar um refrigerante. Encontrou Sérgio no trajeto. As drogas apreendidas não lhe pertencem, nem sabe sua origem.

O simples fato de o réu Sérgio de Souza alegar ser usuário e possuir outra fonte de renda lícita não o impede de exercer a traficância, o que também, aliás, não se mostra incomum. Convém ressaltar a cautela habitual desenvolvida pelos traficantes justamente com o propósito de serem confundidos com usuários.

Os policiais militares apresentaram versão firme, coerente, dizendo que viram o réu Sérgio de Souza abaixado em uma área de "matagal" e que ele foi até um carro, sendo que o motorista fugiu ao perceber a chegada dos policiais. Sérgio trazia consigo duas porções de cocaína e o restante guardava, na área de "matagal", embalada e pronta para comercialização porções idênticas de cocaína.

As declarações de policiais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os policiais tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de numeração suprimida. Sentença condenatória reformada parcialmente em grau recursal, para o fim de diminuir as penas do acusado. Defesa objetiva absolvição pela ilicitude das

provas devido à ilegalidade do flagrante perpetrado por policiais militares. Sem razão. Crime de tráfico é de natureza permanente. Flagrante em conformidade com a lei, obedecendo às determinações legais. Precedentes. Condenação mantida. Nada a reparar no v. acórdão revidendo. Pedido revisional indeferido. (TJ-SP - RVCR: 00087777620208260000 SP 0008777-76.2020.8.26.0000, Relator: Andrade Sampaio, Data de Julgamento: 25/03/2021, 1º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/03/2021).

De outro lado, solução diversa deve ser aplicada a Caio César Pedroso. O contexto fático mostrou-se insuficiente à comprovação do vínculo do acusado com o corréu Sérgio, com quem foram apreendidas as drogas. Observo que nada de ilícito foi encontrado com ele. Consta, pelos relatos dos policiais que fizeram as abordagens, que Caio estava "parado ao lado do veículo".

Assim, a absolvição pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe em relação ao denunciado Caio César Pedroso.

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

Deve ser afastada a causa de aumento relativa ao local onde o crime foi cometido, afinal os entorpecentes foram apreendidos nas proximidades de uma praça pública (fls. 147-148), local que, além de não constar no rol da lei de regência, tampouco se enquadra como "recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza". Ainda, não restou demonstrado que o local conta com quaisquer atrativos que ensejem a aglomeração de grande número de pessoas. Nesse mesmo raciocínio, não há comprovação de que o acusado efetivamente se valeu, ou quis se valer, da aludida proximidade a entidade social e beneficente "Casa de Belém", especialmente porque os fatos ocorreram durante a noite, por volta das 20h00min, período em que, provavelmente as crianças já estariam recolhidas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREQUESTIONADA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. PRAÇA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO PROVIDO. 1. Prequestionada a matéria perante o Tribunal de origem, deve ser conhecido o recurso especial. 2. A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento a fim de reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado (STJ. AgRg no AREsp 1495549/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

"TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA BEM APLICADA - REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO - PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. III, DA LEI DE DROGAS - NÃO ACOLHIMENTO - PRISÃO EM FLAGRANTE NO PERÍODO NOTURNO, AUSENTE, PORTANTO, POTENCIAL DANO AOS FREQUENTADORES DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, HAJA VISTA ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15004796920198260545 SP 1500479-69.2019.8.26.0545, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 01/03/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2021)."

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria.

Inadmissível a valoração como antecedentes criminais o processo criminal em curso (vide certidão fls. 243). O Plenário do STF, em julgamento de repercussão geral, firmou o entendimento de que: "PENAL- FIXAÇÃO -ANTECEDENTES CRIMINAIS - INQUÉRITOS

E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais". (STF RE 591054). O mesmo posicionamento foi cristalizado pelo Enunciado nº 444 da Súmula do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base". O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. É lógico que há de existir o cuidado de evitar "bis in idem". Na hipótese analisada, apesar da diversidade de entorpecentes a quantidade apreendida é pouco expressiva: 5,9 g (cinco gramas e nove decigramas) de cocaína, o réu é primário e não integra organização criminosa, tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico – Suficiência de provas – Manutenção da condenação. Penas – Aumento das básicas por diversidade e natureza dos entorpecentes – Exclusão – Quantidade pouco expressiva – Espécie de um dos tóxicos, por si só, não autoriza exasperação – Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06. Penas – Fixação no piso – Inviável maior diminuição por atenuante – Súmula 231 do STJ. Art. 40, III, da Lei 11.343/06 – Necessidade de demonstração de interesse em propagar o uso de tóxicos entre aqueles que circulam pelos lugares enumerados – Não incidência. Redutor – Cabimento – Réu primário, menor, confesso e sem antecedentes – Redutor máximo – Quantidade não significativa de droga, considerado o peso total. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Possibilidade. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502170-63.2019.8.26.0628; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Fixadas tais premissas, passo a dosar a pena, nos termos dos artigos 59 e 68 do

Código Penal.

SERGIO DE SOUZA

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é tecnicamente primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante e atenuantes.

Considerando a pouca quantidade de entorpecente apreendido, somado ao fato de que o réu é primário e não envolvimento com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade das penas aplicadas, as circunstâncias judiciais favoráveis e sendo o réu primário, o regime é aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena

privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

1) CONDENAR o réu SERGIO DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, em regime aberto, por incurso no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

2) ABSOLVER o réu CAIO CESAR PEDROZO da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

Faculto a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicados.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos .

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA